

1502057-23.2021.8.26.0537

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: CECÍLIA NAIR SIQUEIRA PRADO EUZEBIO

Comarca: Diadema

Foro: Foro de Diadema

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 25/08/2022

... não fica pessoa que não é de tráfico no local. A pessoa pega e sai para não chamar atenção. A sacola estava em um cantinho no chão, próximo a ele. Com o réu foram localizadas porções de "crack", cocaína e maconha. Não foi encontrada quantia em dinheiro. Não conhecia o réu antes dos fatos. O réu confessou que estava na prática do tráfico. Davi confirmou que tinha ido ao local ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Diadema

Foro de Diadema

1ª Vara Criminal

Av. 7 de Setembro, 399, Diadema - SP - cep 09912-010

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1502057-23.2021.8.26.0537 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1502057-23.2021.8.26.0537 2021/001800

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

KAYQUE DOS SANTOS FREITAS

Juiz(a) de Direito: Dr(a). CECILIA NAIR SIQUEIRA PRADO EUZEBIO

Vistos.

KAYQUE DOS SANTOS FREITAS, qualificado à fl. 13, foi denunciado como incurso no artigo 33, "caput", cc. artigo 40, III, ambos da Lei nº 11.343/06, porque, no dia 19 de outubro de 2021, por volta das 14h15, na Rua Manoel Bandeira, altura do nº 304, Campanário, nesta cidade e Comarca de Diadema, trazia consigo e tinha em depósito, 26 porções de "crack", com peso de 5,25g., 18 porções de cocaína, pesando 8,149g., e 23 porções de maconha, no total de 126,96g., substâncias entorpecentes que determinam dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

O réu passou por audiência de custódia às fls. 45/48, ocasião em que lhe foi concedida liberdade provisória, cumulada com medidas cautelares alternativas à prisão.

Notificado (fl. 87), o denunciado apresentou defesa prévia às fls. 108/109.

A denúncia foi recebida em 06/12/2021 (fls. 125/126).

Houve citação (fl. 156) e realizou-se audiência de instrução e julgamento, de forma telepresencial, nos termos do Comunicado CG nº 284/2020, ocasião em que ouvidas duas testemunhas, interrogado o réu e prosseguiu-se com os debates orais entre acusação e defesa.

Em alegações finais, o D. Promotor de Justiça requereu procedência do pedido, condenando-se a ré nos termos da denúncia. No tocante à dosimetria, afirmou ser possível a aplicação do benefício previsto pelo § 4º do artigo 33 da Lei de Drogas,

em que pese o réu ter sido posteriormente preso por outra conduta.

A D. Defesa, por sua vez, postulou a improcedência da ação penal com base na antijuridicidade da conduta, já que o réu enfrentava dificuldades financeiras e morava com sua mãe, irmã e avó, sendo que somente esta trabalhava, tendo realizado a traficância para auxiliar no sustento da família, encontrando-se, assim, em estado de necessidade. Por isso, postulou seja absolvido com base no artigo 386, inciso VI, do Código de Processo Penal, quer seja pelos motivos retro, quer seja, porque a parte final do referido inciso permite a absolvição quando há fundada dúvida acerca da fundada dúvida sobre a presença da excludente de ilicitude acima mencionada. Subsidiariamente, requereu a fixação da pena mínima, por ser o réu primário e sem antecedentes, reconhecendo-se a duplicidade de circunstâncias atenuantes (menoridade e confissão), com a aplicação do redutor de pena em sua fração máxima, e a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, com a fixação do regime inicial aberto.

É o relatório. Fundamento e decido.

Presentes os pressupostos processuais. Ausentes nulidades a sanar.

O conjunto probatório constante nos autos demonstra a veracidade dos fatos narrados na denúncia, com a necessária segurança e certeza, para que seja julgado procedente o pedido condenatório.

A materialidade delitativa restou comprovada pelo teor do boletim de ocorrência (fls. 24/28), das fotografias (fls. 30/31), do auto de exibição e apreensão (fl. 29), do laudo de constatação (fls. 33/35), do laudo de exame químico-toxicológico (fls. 95/97) e da prova oral.

Também a autoria restou devidamente comprovada. Senão vejamos.

Interrogado em Juízo, o réu afirmou que estava desempregado há seis meses. Não fazia bicos. Não tem filhos menores. Não toma remédio controlado. Não tem doença grave. Não é dependente químico. Nunca foi processado antes, somente quando era menor de idade. No tocante aos fatos narrados na denúncia, CONFESSOU a prática do tráfico e disse que sim, realmente estava com as drogas. Afirmou que os entorpecentes estavam todos dentro da sacola. Não sabia que eram policiais e, quando eles o abordaram, correu, mas quando chegou na ponta do escadão já havia dois policiais esperando, os quais retornaram o abordaram e retornaram ao local onde estavam as drogas. Davi estava no local para comprar; era usuário ele. Não conhecia os policiais antes dos fatos e nada tem contra eles. Às perguntas da D. Defensora, respondeu que morava com outros familiares e apenas sua avó trabalhava; sua mãe estava desempregada e suas irmãs menores não recebiam alimentos.

A confissão, ademais, foi corroborada pelas demais provas produzidas sob o crivo do contraditório.

Com efeito, em depoimento bastante seguro prestado a este juízo, a testemunha William Divetta Carrieri, policial civil, afirmou que o local é conhecido como ponto de tráfico, tendo adentrado com seu companheiro de equipe e avistou o réu mexendo em uma sacola num canto. Ele parou de mexer, voltou, chegou uma pessoa perto dele, cumprimentou-o, parecendo serem conhecidos, tendo realizado a abordagem do réu e de DAVI. Em busca pessoal, encontrou pequena quantidade de drogas com o réu e, em conversa informal, ele confirmou que estava no tráfico. Na sacola que ele mexia antes, encontrou outras porções de drogas idênticas a que o réu portava. Quando chegaram o réu estava mexendo na sacola, a deixou em um canto e voltou mais adiante, onde ficou de pé. Depois chegou Davi e eles se cumprimentaram, como se conhecessem. Geralmente não fica pessoa que não é de tráfico no local. A pessoa pega e sai para não chamar atenção. A sacola estava em um cantinho no chão, próximo a ele. Com o réu foram localizadas porções de "crack", cocaína e maconha. Não foi encontrada quantia em dinheiro. Não conhecia o réu antes dos fatos. O réu confessou que estava na prática do tráfico. Davi confirmou que tinha ido ao local comprar drogas. Era usuário.

No mesmo sentido, a testemunha Adriano Moreira Ponte, também policial civil, narrou os fatos à semelhança de seu colega, confirmando, dentre outras coisas, que estava com o companheiro de equipe em viatura descaracterizada, sendo o local dos fatos palco de várias prisões local é conhecido como ponto de tráfico. Avistaram o réu mexendo em uma sacola, depois ele se afastou e, logo em seguida, chegou uma pessoa

que o cumprimentou, tendo realizado a abordagem. Na busca pessoal, foi localizada com ele uma quantidade de drogas e, com o outro indivíduo, não acharam nada. Seu companheiro foi até a sacola que o réu estava mexendo e achou grande porção de drogas. O réu confessou o tráfico informalmente e foi preso em flagrante. A sacola estava na calçada, cerca de um metro, um metro e meio do réu. Eram as três drogas, crack, cocaína e maconha, mas não se recorda a quantidade exata em razão da quantidade de prisões. Não conhecia o réu antes dos fatos. O outro indivíduo disse que ali estava para comprar drogas e, quando se aproximou do réu, eles foram abordados. Às perguntas da D. Defensora Pública, respondeu que acima de vinte porções já considera grande quantidade porque para quem usa é muito. Para quem vende é pouca, mas para quem usa é muita.

Cabe ressaltar, nesse passo, que as palavras dos policiais que atuaram de maneira tão direta não podem ser relevadas ou consideradas suspeitas apenas em razão de sua função, pois seria inadmissível que o Estado, que lhes depositou a tarefa de vigilância e segurança dos estabelecimentos prisionais, desconsiderasse suas palavras justamente quando prestam contas de suas diligências.

Por outro lado, é plenamente compreensível o fato de nenhuma pessoa estranha aos quadros policiais ter sido arrolada para testemunhar em desfavor do réu, porque é sabido que casos de crimes graves, como o tráfico de entorpecentes, a maioria das pessoas evita servir como testemunha, imperando verdadeira "lei do silêncio", por temer sofrer represálias.

Ademais, nada existe nos autos a indicar que os policiais estivessem perseguindo o réu ou que tivessem qualquer motivo para incriminar falsamente pessoa que sequer conheciam e que sabem ser inocente. Ressalte-se que o próprio réu nada falou a esse respeito.

Assim, a credibilidade dos testemunhos dos policiais não pode ser afastada.

Dessa forma, a significativa quantidade de droga apreendida em poder do réu (26 porções de "crack", com peso de 5,25g., 18 porções de cocaína, pesando 8,149g., e 23 porções de maconha, no total de 126,96g.) e as circunstâncias em que se deu sua prisão (policiais realizaram diligência em local conhecido como ponto de venda de drogas, onde visualizaram o réu mexendo em uma sacola. Em seguida, uma pessoa dele se aproximou, cumprimentaram-se, como se estivessem trocando alguma coisa. Em seguida, foram abordados pelos policiais e o réu confirmou que estava no local praticando o tráfico de entorpecentes, o que tornou a confirmar em juízo, sob o crivo do contraditório), evidenciam que, efetivamente, a droga encontrada em poder do réu se destinava à entrega a consumo de terceiros, bem caracterizando a prática do crime de tráfico de entorpecentes, mostrando-se impossível, por consequência, a absolvição por insuficiência de provas ou a desclassificação para a prática do artigo 28 da Lei nº 11.343/06.

A tese defensiva de que o réu teria praticado o crime em virtude de dificuldades financeiras pela qual estaria passando, especialmente pelo fato de que tem duas irmãs menores, uma mãe desempregada e uma avó, que é a única pessoa que sustenta a casa, invocando a excludente de ilicitude prevista no art. 24 do Código Penal ou a causa de diminuição prevista no § 2º do mesmo artigo, não merece prosperar.

Na verdade, não é qualquer dificuldade econômica que abre a possibilidade de atuar o agente amparado por essa causa excludente da ilicitude, mas sim aquela situação eminente que inviabilize a sua própria sobrevivência ou de seus familiares (fome, doença, falta de habitação), o que não logrou êxito a Defesa provar e que seria seu ônus, a teor do que determina o art. 156, CPP.

Além disso, é necessário que a conduta fosse inevitável para evitar o perecimento de seus familiares. Entretanto, o acusado é saudável, estando em plenas condições de desempenhar atividade laborativa lícita e sustentar sua família. Ou seja, a conduta criminosa não era imprescindível – a única saída possível – para evitar um mal maior à sua família.

Logo, não estando presente o estado de necessidade do agente, nem ao menos dúvida fundada sobre a existência dessa condição, não há que se falar em absolvição em razão da exclusão da ilicitude. Nesse sentido, confira-se:

"APELAÇÃO. Tráfico de drogas. Recurso defensivo. Pleito absolutório por insuficiência probatória ou, ainda, pela presença de excludente da ilicitude.

Pleito subsidiário objetivando a aplicação da causa de diminuição prevista no artigo 33, §4º, da Lei de Drogas. 1. Condenação adequada. Prova da materialidade e de autoria. Depoimentos dos policiais uniformes e convergentes, indicando a detenção em flagrante do acusado, bem como a apreensão dos entorpecentes. Credibilidade que não foi afetada diante da ausência de prova em sentido contrário. Modelo probatório que não se filiou ao sistema das provas legais, segundo o qual os meios de prova registrariam valores aprioristicamente determinados pelo legislador. Livre convencimento motivado. Réu confesso. 2. Estado de necessidade não caracterizado. Ausência de elementos que demonstrem o perigo atual ou iminente, aptos a configurar a excludente de ilicitude. Gravidade da conduta praticada pelo acusado que impede o reconhecimento da exculpante, sobretudo porque lhe era exigível atuar de modo diverso. 3. Dosimetria que não comporta reparos. Ausência de circunstâncias judiciais desfavoráveis que permitem a fixação da pena base em seu mínimo legal. Agravante da reincidência integralmente compensada com a atenuante da confissão espontânea. 4. Reincidência que impede a aplicação da figura do tráfico privilegiado e que justifica a imposição de regime prisional mais severo, afastando a possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Bis in idem não configurado. Precedentes. 5. Recurso conhecido e desprovido." (TJSP; Apelação nº 1500951-26.2021.8.26.0537; Relator Des. Marcos Alexandre Coelho Zilli; 16ª Câmara de Direito Criminal; Julgamento: 22/11/2021; Data de Registro: 22/11/2021).

Assim, não restou configurada nenhuma causa de exclusão de tipicidade, ilicitude ou culpabilidade, havendo provas suficientes para que seja condenado o réu nas sanções do artigo 33, "caput", da Lei 11.343/06.

Passo, deste modo, à dosimetria da pena, de forma individualizada, com observância ao princípio da humanidade, nos termos do art. 5º, XLVI da CF/88 e arts. 59 e 68, ambos do Código Penal Brasileiro.

Considerando as disposições do artigo 59 do Código Penal, verifico que o réu não ostenta Maus antecedentes (fls. 65/66 e 106). Culpabilidade normal ao tipo; ausentes elementos para aferir personalidade ou conduta social; motivos, circunstâncias e consequências próprios da conduta. Assim, fixo a pena-base no piso legal, ou seja, em 05 anos de reclusão e pagamento de 500 dias-multa. O dia-multa será à razão mínima, ante a falta de informações acerca das condições financeiras pessoais do réu.

Na segunda fase, presente a circunstância atenuante da menoridade relativa (réu nascido em 06/07/2003 - fl. 13) e a circunstância atenuante da confissão espontânea; entretanto, impossível a redução da pena neste momento, porque já está no piso legal e, nos termos da Súmula nº 231 do Superior Tribunal de Justiça, não pode ser conduzida aquém desse patamar, neste momento do cálculo.

Por fim, reconheço possibilidade de aplicação da causa de diminuição prevista no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, já que o réu é primário, sem antecedentes criminais e não se vislumbra qualquer demonstração eficaz de que se dedique a atividade criminosa ou integre organização criminosa, motivo pelo qual ele faz jus à redução na proporção de 2/3, alcançando o montante de 01 ano e 08 meses de reclusão e pagamento de 166 dias-multa, a qual torno definitiva por não encontrar nenhuma outra circunstância modificadora aplicável.

O regime inicial de cumprimento será o ABERTO, uma vez que este se revela suficiente à prevenção e repressão do crime. Ressalto, aliás, a tendência de nossos Tribunais Superiores no sentido de que o tráfico em sua forma privilegiada (§ 4º do artigo 33) não é considerado como hediondo e, bem por isso, de que, se as demais circunstâncias do caso concreto não evidenciam a necessidade de fixação de regime rigoroso, é possível a fixação de regime mais brando.

Impossível, entretanto, a substituição da pena, uma vez que insuficiente a repressão do crime, especialmente diante da quantidade e variedade das drogas, bem como porque o réu, no curso da liberdade provisória concedida nesses autos, foi preso por outro feito, de forma que não se revela socialmente adequada a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

Ante o exposto, julgo PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal e, em consequência, CONDENO a ré KAYQUE DOS SANTOS FREITAS à pena de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de

reclusão, em regime inicial aberto, e ao pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, no valor unitário mínimo legal, por infração do artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06.

Como respondeu solto a este processo, defiro-lhe o direito de recorrer em liberdade, pois não estão presentes os requisitos necessários à decretação de sua prisão cautelar.

Com o trânsito em julgado, expeça-se guia de recolhimento definitiva.

Defiro os benefícios da assistência judiciária gratuita, observando-se o disposto no art. 4º, §, 9º, "a", da Lei Estadual 11.608/03 e art. 98, §3º, do CPC, especialmente considerando a renda do réu, declarada em audiência, e a situação de hipossuficiência financeira por ele informada.

Caso não haja recurso desta sentença, oficie-se para destruição das amostras do entorpecente guardadas para contraprova, nos termos do artigo 72 da Lei nº 11.343/06, cabendo ressaltar que por ocasião da audiência de custódia já houve determinação de destruição do entorpecente, reservando-se apenas o necessário à realização do laudo definitivo.

Publique-se e intimem-se. Façam-se as anotações e comunicações de praxe.

Diadema, 25 de agosto de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA